

教授Xと学生Yは、事後強盗罪の共犯に関する事例について後記【会話】のとおり検討している。【会話】中の①から④までの()内から適切な語句を選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【会 話】

教授X. 窃盗犯人甲は、自己を逮捕しようと追い掛けてきた被害者Vに対し、逮捕を免れる目的で、Vの反抗を抑圧する程度の暴行を加えました。甲にはどのような犯罪が成立しますか。

学生Y. 甲には事後強盗罪が成立します。

教授X. それでは、甲がVから追い掛けられている時に、甲の知人乙が、偶然通り掛かり、その状況から甲がVの物を盗んだのだと認識し、甲と意思を通じて、甲の逮捕を免れさせる目的で、Vに対し、Vの反抗を抑圧する程度の暴行を加えた場合、乙の共犯としての罪責はどうなりますか。

学生Y. 事後強盗罪を真正身分犯と考え、刑法第65条についての判例の立場に立てば、乙には①(a. 刑法第65条第1項により事後強盗罪・b. 刑法第65条第2項により暴行罪)が成立します。

教授X. 事後強盗罪を不真正身分犯と考える立場では、乙の共犯としての罪責はどうなりますか。

学生Y. 事後強盗罪を不真正身分犯と考えた上で、刑法第65条第1項は構成的身分及び加減的身分を通じて、身分犯における共犯の成立の規定であり、同条第2項は加減的身分について刑の個別作用を定めたものと解する立場に立てば、乙には②(c. 刑法第65条第1項により事後強盗罪が成立するが、同条第2項により暴行罪の刑を科す・d. 刑法第65条第1項と同条第2項の双方を適用して、暴行罪が成立する)ことになります。

教授X. 事後強盗罪を身分犯と考えない立場では、乙の共犯としての罪責はどうなりますか。

学生Y. 事後強盗罪を窃盗と暴行の結合犯と考える立場もあります。この立場に立ち、乙に事後強盗罪が成立するという考え方は、乙の承継的共同正犯を③(e. 肯定・f. 否定)しています。

教授X. 事後強盗罪を結合犯と考える立場に対しては、どのような批判がありますか。

学生Y. ④(g. 窃盗の既遂・未遂によって事後強盗罪の既遂・未遂が決まることを説明できない・h. 窃盗に着手しただけで事後強盗罪の未遂を肯定することになってしまうのではないか)という批判があります。

1. ①a ②d ③e ④g
2. ①b ②d ③f ④h
3. ①a ②c ③e ④h
4. ①b ②d ③f ④g
5. ①a ②c ③e ④g

No171

H27-13

事後強盗罪の共犯

正解

3

正答率

56%

①=a

①には、直前の記述より、事後強盗罪を真正身分犯と考え、かつ、65条について判例の立場に立った場合に、乙に適用される条文及び成立する犯罪が入る。判例は、65条について、1項は真正（構成的）身分犯に関する規定、2項は不真正（加減的）身分犯に関する規定と解している（最判昭31.5.24）。判例の立場に立ち、事後強盗罪を真正身分犯と考えた場合、事後強盗罪の共犯である乙には「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。」とする65条1項が適用され、事後強盗罪が成立する。したがって、①にはaが入る。

②=c

②には、直前の記述より、事後強盗罪を不真正身分犯と考え、かつ、65条について、1項は構成的身分及び加減的身分を通じた身分犯における共犯の成立の規定であり、2項は加減的身分について刑の個別作用を定めたものであると解する立場に立った場合に、乙に適用される条文及び成立する犯罪が入ることが分かる。そして、事後強盗罪を不真正身分犯すなわち加減的身分犯と考え、かつ、65条に関する上記見解に立った場合、加減的身分犯である事後強盗罪の共犯である乙に対する65条の適用及び成立する罪名並びに科刑は以下ようになる。まず、罪名につき、「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。」と規定する65条1項が適用され、事後強盗罪が成立する。次に、科刑につき、「身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。」と規定する同条2項が適用され、暴行罪の刑が科せられる。したがって、②にはcが入る。

③=e

③には、直前の記述より、事後強盗罪を窃盗と暴行の結合犯と考えた場合に、その共犯である乙に事後強盗罪の成立を認める立場に立つ、承継的共同正犯の肯否が入ることが分かる。承継的共同正犯とは、先行者が既に実行行為の一部を終了した後、後行行為者が関与する形態の共犯のうち、共同実行の意思をもって参加した場合をいう。そして、事後強盗罪を窃盗と暴行の結合犯と考えた場合、乙は、先行者である甲が、既に実行行為の一部である窃盗を終了した後、その事情を知った上、共同実行の意思をもって、後行行為である暴行に関与した者であり、承継的共同正犯に当たる。とすると、事後強盗罪を窃盗と暴行の結合犯と考えた上、乙に事後強盗罪を成立する立場は、乙の承継的共同正犯を肯定する立場である。したがって、③にはeが入る。

④=h ★

④には、直前の記述より、事後強盗罪を結合犯と考える立場に対する批判が入ることが分かる。事後強盗罪を窃盗と暴行の結合犯と考えると、窃取行為も事後強盗罪の実行行為だということになる。とすると、窃盗に着手した時点で、事後強盗罪の実行行為への着手が認められ、事後強盗罪の未遂が肯定されてしまうのではないかという批判が向けられている。したがって、④にはhが入る。